

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الرابعة)

اسم العادة :- تنازع القوانين

تاريخ الإمتحان :- الخميس ٤ / ٦ / ٢٠٢٤

نظام الإمتحان :-

قضيه إجباري : ٣٠ درجة

سؤالين مقالي علي الطالب اخيار سؤال واحد فقط : ٣٠ درجة

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص : ٣	س١: حدد المقصود بالتكييف مبيناً موقف المشرع المصري منه؟ صيغة أخرى :- اكتب في مشكلة التكييف في القانون الدولي الخاص ؟
ص : ٤	س٢: ما المقصود بالإحالة مبيناً صورها وموقف القانون المصري من الاحالة؟ صيغة أخرى :- عرف الأحالة وصورها وموقف المشرع المصري منها ؟
ص : ٥ : ٦	س٣:- حدد حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالميراث والتركات وما هو القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي الميراث اذا توافرت احدي هذه الحالات ؟
ص: ٧	س ٤: اشرح حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة ؟

2026

س١: حدد المقصود بالتكييف مبيناً موقف المشرع المصري منه؟
صيغة أخرى :- اكتب في مشكلة التكييف في القانون الدولي الخاص ؟

أولاً: تعريف التكييف:

- ١ تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية لكي يسند حكمها إلي قانون معين
- ٢ تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية لكي يسند حكمها إلي قانون معين .
- ٣ فمثلاً في نطاق القانون المدني يواجه القاضي مشكلة التكييف عندما يتصدي لتحديد وصف الرابطة العقدية المطروحة امامه وصفاً قانونياً سليماً لينتهي الي ما اذا كان العقد محل النزاع عقد ايجار او عقد بيع او عقد هبة .
- ٤ في نطاق القانون الجنائي يواجه القاضي مشكلة التكييف عندما يتصدي لوصف الفعل الذي ارتكبه المتهم لمعرفة ما اذا كان يعتبر من قبيل السرقة او الاختلاس او خيانة الامانة .
- ٥ **مرحلة التكييف هي أول ما يعرض له القاضي عندما تقدم له مسألة تشتمل على عنصر اجنبي**، إذ يجب عليه قبل كل شيء، أن يدخل العلاقة المعروضة عليه في نظام من النظم القانونية، حتى يعرف ما هو القانون الذي يسند إليه حكمها، **أي أن مرحلة التكييف تسبق بالضرورة مرحلة الإسناد.**

ثانياً: موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف:

- ١ إن الفقه المؤيد لتطبيق قانون القاضي بالنسبة للتكييف، قد استقر على أن إعمال قانون القاضي قاصر على التكييف الأولي أو الأساسي، أي الذي تتحدد به طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين دون التكييفات اللاحقة التي يتطلبها القانون الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد، فهي تخضع لذلك القانون ذاته.
- ٢ ورأى بارتان أن إخضاع التكييفات اللاحقة للقانون الواجب التطبيق قيد على نظريته، وذلك اتفاقاً مع أساس تلك النظرية وهو فكرة السيادة، إذ ما دام تبين اختصاص القانون الأجنبي فلا داعي في الاستمرار في الرجوع إلى قانون القاضي، وقد أخذ القضاء برأي بارتان، وشايعته كثير من التشريعات، ومنها القانون المدني المصري .

وبذلك ينضج لنا موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف :

- ١ تأثرت كثير من التشريعات ومنها التشريع المصري بنظرية بارتان،
- ٢ **وأخضعت التكييف (السابق) لقانون القاضي. فقد نصت المادة ١٠ من القانون المدني المصري** على أن القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات، عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.
- ٣ **التكييف (اللاحق)** فيخضع للقانون الواجب التطبيق من الواضح، أن التكييف الذي يخضع للقانون المصري، هو التكييف اللازم لتحديد القانون الواجب التطبيق، وبذلك يكون المشرع المصري قد أخذ بالتفرقة بين التكييف الأساسي أو الأولي، والتكييف الثانوي أو اللاحق.
- ٤ **المقصود بالقانون المصري** ← الذي يرجع إليه في شأن التكييف وفقاً للمادة العاشرة من القانون المدني هو القانون المصري في جملته بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو الأموال أياً كان مصدر هذه القواعد وكذلك المبادئ العامة في القانون المصري

ثالثاً: التكييف وقاعدة الإسناد المتفق عليها في معاهدة:

- ١ قد ترد قاعدة الإسناد في معاهدة دولية، وعندئذ إذا اتفق في المعاهدة على تكييف معين وجب اتباعه.
- ٢ والاتفاق على التكييف قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً، على أن الأمر يثار عندما يتفق في المعاهدة على قاعدة إسناد، ولا ينص على التكييف اللازم لتطبيقها. ويرى بارتان أنه في هذه الحالة، يتولى القاضي في كل دولة إجراء التكييف على ضوء ما تقضي به النظم القانونية الداخلية في دولته.

س٢: ما المقصود بالإحالة مبيناً صورها وموقف القانون المصري من الإحالة؟

صيغة أخرى :- عرف الإحالة وصورها وموقف المشرع المصري منها ؟

أولاً: ماهية الإحالة :

المقصود بالإحالة ← تلك النظرية التي تقضي بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق على العلاقة، بمقتضى قواعد التنازع الوطنية.

نشأة مشكلة الإحالة (قضية فورجو):

لم تظهر مشكلة الإحالة إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بمناسبة القضية المشهورة التي عرضت على القضاء الفرنسي سنة ١٨٧٨ وهي قضية فورجو وتتلخص وقائعها، في أن فورجو هذا كان ولداً غير شرعي، ونزحت به أمه وهو طفل في الخامسة من العمر إلى فرنسا وأقام هناك إقامة فعلية، دون أن يتخذا لهما موطناً قانونياً في فرنسا، وعندما شب فورجو، تزوج من فرنسية ثرية، ماتت وتركت له ثروة منقولة طائلة، وفي الثامنة والستين من العمر توفي فورجو بمدينة (بورجو) تاركاً هذه الثروة المنقولة دون أن يترك ورثة مباشرين، أي دون أب أو أم أو أخوة.

لما كان القانون الفرنسي لا يعطي الحق في ميراث الولد غير الشرعي إلا لأبوه وأخوته فقط، فقد استولت مصلحة الأموال الفرنسية على هذه الثروة باعتبارها تركة بال وارث. فطالب الحواشي من أقارب أمه بالميراث، فقضت محكمة استئناف (بورجو) برفض طلبهم مستندة إلى أن فورجو كان متوطناً بفرنسا، وبالتالي يجب أن يطبق على ميراث ثروته المنقولة القانون الفرنسي، وهو يقضي بحرمان غير الأبوين والأخوة للولد غير الشرعي من ميراثه. ثم توالى أحكام القضاء الفرنسي على هذا النحو، آخذة بالإحالة، واستمر قضاء هذه المحكمة مضطرباً في هذا الاتجاه حتى الآن.

ثانياً: صور الإحالة :

للإحالة صورتان:

أ- إحالة من الدرجة الأولى ← حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون القاضي.

مثال ذلك ← أن يقوم انجليزي مقيم بفرنسا بصرف متعلق بأهليته، فيطبق عليه القانون الفرنسي قانون جنسيته وهو القانون الإنجليزي، ولكن قواعد التنازع في القانون الإنجليزي تحيل إلى قانون الموطن وهو القانون الفرنسي، وتسمى هذه الصورة الرجوع.

ب- إحالة من الدرجة الثانية ← حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون ثالث. كما لو كان هذا الإنجليزي متخذاً له موطناً في إيطاليا، ورفع الأمر إلى القاضي الفرنسي، فإنه لو قبل إحالة القانون الإنجليزي إلى القانون الإيطالي، فسوف يطبق القانون الإيطالي. وقد تتعدد الإحالة في هذه الصورة، إذ قد يحيل القانون الإيطالي إلى قانون رابع.

ثالثاً: موقف القانون المصري من شأن الإحالة :

لم يؤخذ المشرع المصري بالإحالة، وقد نصت المادة ٢٧ من القانون المدني المصري على أنه إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص، نخلص من ذلك، إلى أن الإحالة هي نظرية تقول بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

س٣:- حدد حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالميراث والتركات وما هو القانون الذي تطبقه المحكمة المصرية علي الميراث اذا توافرت احدي هذه الحالات ؟

أولاً: حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالميراث:

لاحظ المشرع عند تحديده لقواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الجمهورية الصلة الوثيقة بين الدعاوي التي ترفع بشأن أرث او تركة ومن ثم رأي ان يجمع بينها في صعيد واحد من حيث الإختصاص فلم يعتد في تقريره إختصاص محاكم الجمهورية بمحل إقامة او توطن المدعي عليه كما لم يعتد بصفة المدعي وكونه وارثا ام من الغير كذلك لم يعتد بسبب الدعوى وكونها تتعلق بالمطالبة بحق في الارث او بدين علي التركة او بقسمتها او بإدارتها وإنما إشتراط فقط لإختصاص محاكم الجمهورية بجميع الدعاوي المتعلقة بالارث او التركة **توافر احد الشروط ثلاث تضمنتهم المادة ٣١ علي سبيل الحصر:**

➤ **الشرط الاول** ← ان تكون التركة قد افتتحت بجمهورية مصر العربية وتعتبر التركة قد افتتحت بالجمهورية إذا كانت الجمهورية هي اخر موطن للمورث.

➤ **الشرط الثاني** ← ان يكون المورث مصري ويرجع في تحديد جنسية المورث الي احكام تشريع الجنسية في جمهورية مصر العربية.

➤ **الشرط الثالث** ← ان توجد اموال التركة كلها او بعضها بإقليم الجمهورية ويستوي في هذا الصدد ان يكون المال الموجود بإقليم الجمهورية منقولاً ام عقاراً.

➤ علي ذلك إذا توافر اي من الشروط الثلاث السابقة اختصت المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأرث او التركة.

ثانياً: القانون الواجب التطبيق علي الميراث:

➤ **القاعدة** ← **تنص المادة ١٧ مدني علي أنه (يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت يطبق عليها قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته سواء وقع التصرف علي عقار أو علي منقول**

➤ ادخل القانون المصري والقوانين العربية الميراث في نطاق الاحوال الشخصية واخضعه كله سواء وقع على عقار او على منقول **لقانون جنسية المتوفى** ، وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول فتخضع الميراث في العقار لقانون موقعه والميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى .

➤ **اما في مصر** فقد ايد جانب من الفقه المصري اخضاع الميراث لقانون الجنسية استنادا الي الصلة الوثيقة بينه وبين روابط الاسرة ، فضلا عن ان ذلك يؤدي الى وحدة القانون الواجب التطبيق على التركة كلها .

➤ علي ان هناك جانبا آخر من الفقه المصري ، يرى ان وحدة القانون الذي تخضع له التركة ، يمكن ان تتحقق بغير تطبيق قانون جنسية المتوفى ، ويشير هذا الرأي الى وجوب تطبيق قانون موطن المتوفى على التركة منقولة كانت او عقارية علي أساس أن أموال الشخص غالباً ما توجد في الدولة التي يتوطن فيها ومهما يكن من أمر الخلاف السابق فقد حسمه المشرع وأخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى .

مجال تطبيق قانون جنسية المتوفى :

١- يبين قانون جنسية المتوفى شروط استحقاق الارث ، وهى تدور حول موت المورث (حقيقة او حكما) وحياء الوارث ، وهل يشترط تحقيق حياة الوارث حقيقة وقت موت المورث ، ام يكفى تحقق حياته حكما

٢- يبين كذلك من هم الورثة ومرتبة كل منهم وانصبتهم وموانع الارث ، وحالات الحجب .

٣- قانون جنسية المتوفى تحديدها بيان الحقوق والالتزامات التى تنقل الى الورثة وكيفية انتقالها ووقته ففى الشريعة الاسلامية تنقل الحقوق دون الالتزامات الى الوارث ومن ثم

لا يجوز التنفيذ على اموال الوارث وفاء لدين المورث .

مدى تدخل قانون موقع المال :

🌟 اذا كان المشرع المصرى قد اخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى الا أن قانون موقع المال هو الذى يبين

هل فرق المشرع المصري بين المنقول والعقار في **المسائل الاتية :**

١- مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفها ضمانا لهذه الديون ، وعلى ذلك فالقانون المصرى هو الذى ينطبق بالنسبة لقاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون ، ما دامت اموال التركة موجودة فى مصر ولو كان المورث اجنيا .

٢- شهر حق الارث بالنسبة للعقارات وتحديد الاثار المترتبة على هذا الشهر .

٣- يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثة وكيفية ادارة اموال التركة الشائعة .

حكم التركة الشاغرة :

🌟 قد يتوفى اجنبى عن تركة تتضمن اموالا موجودة فى مصر ويتضح من قانون جنسية المتوفى إنه لا وارث له ، او ان ورثته تنازلوا عن حقهم ، وفى ايلوله اموال التركة تتجه بعض التشريعات الى ايلولتها للدولة التى توجد فيها **باعتبار ان الدولة هى وارث من لا وارث له** ، وبعضها يتجه الى ايلولتها لدولة جنسية المتوفى او دولة موطن المتوفى .

س٤: اشرح حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة ؟

❁ بإستقراء المواد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الجمهورية نجد أن هناك حالات اختصاص للمحاكم المصرية هدفها تحقيق اعتبارات العدالة ومراعاة لصالح المدعي حيث أن هذه الحالات مستمدة من طبيعة النزاع وهي مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة .

❁ **نص المشرع المصري** ← تنص المادة ٧/٣٠ مرافعات علي ان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوي متعلقة بمألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً او كان اجنبياً له موطن في الجمهورية وذلك اذا لم يكن للمدعي عيله موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوي

❁ قد قرر المشرع حالتان لاختصاص المحاكم المصرية وفقاً لهذا النص الغرض منها تلافي انكار العدالة في الاولى اما الثانية قائمة علي اساس القانون الواجب التطبيق في الدعوي

الحالة الاولى: اختصاص المحاكم المصرية القائم علي فكرة تجنب انكار العدالة

❁ يشترط الاختصاص المحكمة المصرية وفقاً لهذه الحالة :

١- ان يكون النزاع متعلق باحدي مسائل الاحوال الشخصية

❁ يرجع في تحديد المقصود بالاحوال الشخصية لقانون القاضي لاعتبارها مسألة تكييف يتوقف عليها تحديد اختصاص المحكمة وتشمل الاحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم او المتعلقة بنظام الاسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والاقرار بالأبوة وانكارها والعلاقة بين الاصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والاصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة وكذلك المنازعات المتعلقة بالمواريث والوصاية

٢- **ان يكون المدعي مصري الجنسية او اجنبي له موطن في مصر:-** وفقاً لهذا الشرط يجب أن يكون المدعي مصري الجنسية حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر أو أن يكون أجنبياً له موطن في مصر ولا يكتفي بمجرد إقامته بمصر في هذه الحالة .

٣- ان يكون المدعي عليه اجنبياً ليس له موطن او محل إقامة في مصر لأن لو كان للمدعي عليه موطن او اقامة في مصر لكانت المحكمة المصرية مختصة وفقاً لنص المادة ٢٩ مرافعات

٤- الا يكون للمدعي عليه موطن معروف في الخارج

❁ يمثل هذا الشرط الغرض من هذه الحالة وهي تجنب انكار العدالة حيث ان المدعي عليه ليس له موطن في مصر وكذلك ليس له موطن معروف في الخارج فكيف يمكن للمدعي الحصول علي حقه والحماية القضائية له فواجب الدولة هو اداء العدالة نحو مواطنيها وكذلك للمواطنين فيها

الحالة الثانية : الاختصاص القائم علي اساس ان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق في الدعوي :

❁ شروط اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة :

أ- ان يكون النزاع متعلق باحدي مسائل الاحوال الشخصية

ب- ان يكون المدعي مصري الجنسية او اجنبي له موطن في مصر

ج- **ان يكون المدعي عليه اجنبياً ليس له موطن او محل إقامة في مصر** ← لأن لو كان للمدعي عليه موطن في مصر لكانت المحكمة المصرية مختصة وفقاً للمادة (٢٩) مرافعات .

د- **ان يكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علي النزاع**

❁ يمثل هذا الشرط احدي حالات جلب الاختصاص التشريعي للإختصاص القضائي حيث ان القانون الواجب التطبيق في الدعوي يعد احد شروط اختصاص المحكمة ويبرر اختصاص المحكمة المصرية في ذلك انها الاقدر علي تطبيق القانون المصري في مسائل الاحوال الشخصية من اي محكمة اجنبية فضلاً عن انه من المرغوب فيه ان تكفل محاكم الدولة تطبيق قانونها بنفسها .